

제61회 변리사 제2차시험

특허법 해설

한빛변리사학원
특허법 강사 일동

안녕하세요.

한빛 특허 강사진입니다.

시험 치시느라 고생 많으셨습니다.

올해 특허법 시험은 어려웠다고 판단됩니다.

문제 자체의 난이도는 별론으로, 문제의 길이, 종전에 접하지 못하였던 방식의 유형이 다수 출제되었기에, 출제된 판례 자체는 익숙한 판례임에도 불구하고, 생소함을 많이 느끼셨을 문제라고 판단됩니다. 특히, 상술한 사유들로 인해, 시험장에서의 체감 난이도는 극도로 높았을 것으로 생각합니다.

다만, 문제 각각, 설문 각각을 분리해서 살펴보면, 크게 논란이 되거나, 출제자의 의도를 도저히 파악할 수 없는 수준의 문항은 없는 것으로 파악됩니다.

짧지 않은 시간 동안 수고 많으셨습니다.

한빛 특허 강사진 일동 올림

*본 자료는 한빛 특허 강사진의 의견에 불과하므로, 이의신청의 근거가 될 수 없습니다.

[문제 - 1]

주식회사 甲은 2021. 5. 1. 자신의 발명을 대리인 없이 스스로 다음과 같이 특허출원하였다.
[이하 '선출원'이라 한다.]

[발명의 상세한 설명]

A

[특허청구범위]

[청구항 1] A

이후 주식회사 甲은 A 발명을 개량하였고, A 발명 및 개량 발명에 대하여 주식회사 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며(다만 우선권의 승계는 별도로 하지는 않음), 주식회사 乙은 변리사 김특허를 대리인으로 선임하였다.

변리사 김특허는 2022. 4. 1. '주식회사 乙'을 출원인으로 기재하고, 대리인란에 자신과 자신이 선임한 복대리인 변리사 이실용을 기재하면서 위임사항란에 "특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차"라고만 기재된 위임장을 각각 첨부하였고, 위 선출원을 기초로 특허법 제55조의 우선권을 주장하면서(출원시 그 취지를 기재하고 선출원을 표시하였으며, 다만 우선권주장서류는 별도로 제출하지는 않음) 다음과 같이 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

A, A+B

[특허청구범위]

[청구항 1] A

[청구항 2] A+B

주식회사 乙은 특허출원시부터, A 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丙에게 월 2,000,000원의 로열티를 지급받고 있고, A+B 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丁에게 월 3,000,000원의 로열티를 지급받고 있다.

한편, 주식회사 戊는 A 발명을 2022. 2. 1.부터 주식회사 乙의 허락 없이 지역사회의 발전을 위하여 비영리로 실시 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 특허청은 2022. 6. 1. 자 보정 요구서를 발송하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오. (5점)

(2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. (7점)

(3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리 행사에 필요한 절차를 설명하시오. (8점)

(4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊가 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하시오.

2) 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오.

3) A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오.

설문(1)은, 특별수권사항을 묻는 조문 문제입니다. 우선권주장에 대한 기본기를 묻는 문제인 만큼, 조문 위주로 해결할 수 있는 문제입니다. 사실관계 중간에 일부 함정이 있는데, 여기에 걸려들지 않는 것이 중요한 문제였습니다. 설문(2)는, 단문 문제입니다. 개량 발명으로는 특유발명을 위주로 기재하면 되겠습니다. 설문(3)은, 보상금청구권 일반론과 함께 사안포섭을 하면 되는 문제입니다. 설문(4)는, 보상금청구권 관련하여 답을 내야 하는 문제입니다. 답을 맞추는 것이 중요하겠습니다. 따로 분리해서 살펴보면 어렵지 않지만, 문제 길이와 첫 번째 문제라는 점에서 많이 당황하셨을 법한 문제입니다.

(1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 특허청은 2022. 6. 1. 자 보정 요구서를 발송하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오. (5점)

I. 설문(1)

1. 절차보정명령(法46) 및 대리권 증명의 방식(法7)

2. 특별수권 사항(제6조)

3. 사안의 해결 - 보정 요구서의 구체적인 내용 및 취지

(1) 국내우선권주장에 대한 대리권 증명서류 제출 요구

변리사 김특허는 특별수권 없이 국내우선권주장(法55)을 하였다. 따라서, 보정 요구서에서는 국내우선권주장에 관한 대리권 증명서류가 제출되어야 한다는 취지가 기재되어 있을 것이다.

(2) 복대리인 선임에 대한 대리권 증명서류 제출 요구

변리사 김특허는 특별수권 없이 복대리인 변리사 이실용을 선임하였다. 따라서, 보정 요구서에는 복대리인 선임에 관한 대리권 증명서류가 제출되어야 한다는 취지가 기재되어 있을 것이다.

(3) 권리의 승계 입증 요구

① 乙은 갑으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으므로, 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다(判例). 이는 조약우선권주장과 달리 우선권 승계를 필요로 하지 않는다.

② 다만, 특허청장은 권리승계 여부를 판단하기 위해 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 입증할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있을 것이다.

(4) 기타 사유 검토

국내우선권주장 시에는 취지를 기재하고 선출원을 표시하면 충분하고 우선권주장서류는 제출할 필요가 없다(法55②). 따라서 이는 보정요구의 근거가 될 수는 없다.

(2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. (7점)

II. 설문(2)

1. 국내우선권주장의 취지

- 1) “국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다”(2017후1274).
- 2) 즉, 국내우선권을 주장하면 개량 발명에 대해 누적된 성과를 보호받게 되는 장점이 있다.

2. 개량 발명의 예

(1) 선택발명

공지발명에 상위개념이 기재되어 있고, 출원발명에 하위개념이 기재되어 있는 선택발명은 개량 발명에 해당한다.

(2) 수치한정발명

공지발명에 포함되어 있는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 수치한정발명은 개량 발명에 해당한다.

(3) 의약용도발명

의약용도발명이란 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약으로서의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 개량 발명에 해당한다.

(4) 여러 인용발명을 결합하여 완성된 발명

복수 개의 발명을 결합하여 완성되는 발명은 개량 발명에 해당한다.

(3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리 행사에 필요한 절차를 설명하시오. (8점)

III 설문(3)

1. 보상금청구권 의의(法65②)

① 등록 이전의 출원발명에 대한 제3자의 도용으로부터의 보호 규정으로, 경고를 받거나 악의로 출원발명을 업으로 실시한 자에게 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. ② 특허권과 독립적인 권리로, 해제조건부 권리이며, 채권적 권리이다.

2. 보상금청구권 성립 요건

(1) 성립요건 일반

- ① 특허출원이 출원공개되어야 한다.
- ② 출원인이 서면으로 경고하거나 실시자가 공개된 발명을 알고 있어야 한다.
- ③ 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 출원발명을 실시하여야 한다.

(2) 사안의 경우

- ① 乙 출원은 선출원일(2021. 5. 1.)로부터 18개월이 경과한 때(2022. 11. 1.) 출원공개되었다.
- ② 戊이 악의인 경우 보상금청구권이 발생할 것이지만, 악의가 아닌 경우 서면경고가 필요하다.
- ③ 戊는 비영리 실시자이지만, 이와 별론으로 업으로서의 실시이므로 보상금청구권은 발생한다.

3. 권리 행사에 필요한 절차

(1) 일반

보상금청구권은 출원발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法65③).

(2) 사안의 경우

- ① 乙은 戊의 악의가 확실하지 않으므로 戊에게 서면경고를 하여야 한다.
- ② 乙은 보상금청구권을 설정등록 이후에 행사할 수 있다.
- ③ 乙은 이를 위해, 심사청구를 할 수 있고, 戊의 실시를 이유로 우선심사를 신청할 수 있다.

(4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊가 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하시오. (10점)

- 1) 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하시오.
- 2) 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오.
- 3) A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오.

III. 설문(4) - 1)

1. 보상금청구권의 소멸시효

- 1) 보상금청구권을 행사하는 경우에는 민법 제766조(손해배상청구권의 소멸시효)가 준용된다. 이 때 단기소멸시효의 기산점은 해당 특허권의 설정등록일이 된다.
- 2) 따라서, 보상금청구권은 해당 특허권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다(法65⑤).

2. 사안의 해결

- ① 乙의 특허출원은 2023. 10. 1. 설정등록되었으므로 乙의 戊에 대한 보상금청구권은 2026. 10. 1.까지 행사할 수 있다.
- ② 따라서 乙이 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한은 2026. 10. 1.이다.

IV. 설문(4) - 2)

1. 보상금청구권의 합리적 실시료 상당액 산정(法65②)

- 1) 특허출원인은 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간에 대한 보상금을 청구할 수 있다.
- 2) 특허출원인이 해당 기간에 대하여 청구할 수 있는 보상금은 해당 기간의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금이다. 즉, 합리적 실시료 상당액을 청구할 수 있다.

2. 사안의 해결

- ① 乙은 丙이 경고를 받은 날(2023. 2. 1.)부터 설정등록일(2023. 10. 1.)까지의 8개월에 대한 보상금을 청구할 수 있다.
- ② 乙은 A 발명의 실시에 대하여 丙에게 월 2,000,000원의 로열티를 지급받고 있으므로, A 발명에 대한 합리적 실시료 상당액은 월 2,000,000원으로 볼 수 있다.
- ③ 따라서, 乙이 戊에게 받을 수 있는 예상 금액은 8개월 X 2,000,000원 = 16,000,000원이다.

V. 설문(4) - 3)

1. 특허권의 존속기간(法88)

2. 국내우선권주장의 취급

국내우선권주장출원의 경우 특허권의 존속기간의 기산일은 우선권주장출원일을 기준으로 한다.

3. 사안의 해결

A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 국내우선권주장출원일(2022. 4. 1.)을 기준으로 20년이 되는 날인 2042. 4. 1.이 된다.

[문제 - 2]

甲은 다음 특허 제10-0000000호의 특허권자이다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A, B를 포함하는 기계장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 기계장치.

[청구항 3] 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 기계장치.

甲은 乙에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 발송하였고, 특별한 답변이 없자 乙을 상대로 특허 심판원에 청구취지 및 확인대상발명을 다음과 같이 기재하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[청구취지]

확인대상발명은 특허 제10-0000000호 제2항의 권리범위에 속한다.

심판 비용은 피청구인이 부담한다.

[확인대상발명]

A', B, C를 포함하는 기계장치.

위 심판에서 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명 중 구성 C는 자신이 실시하는 발명 C'과는 사실적 관점에서 동일성이 없다고 주장하였고(다만 구성 C 및 C'은 균등관계라고 판단될 수는 있음), 특허심판원은 심리를 통하여 甲이 특정한 확인대상발명의 구성 중 A' 및 B는 乙이 실시하고 있다고 인정하였으나, 확인대상발명의 구성 중 C는 乙이 주장하는 C'과는 상이하다는 심증을 얻었으며, 이를 이유로 甲에게 확인대상발명에 대한 보정의 기회를 부여하였다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다.

이후 특허심판원은 甲의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. (단, 다음 각 물음은 독립적이다.)

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하시오. (5점)

- 1) 청구취지의 특정
- 2) 청구원인의 특정
- 3) 확인의 이익

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장은 심리하지 않으면서, 독자적으로 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하시오. (8점)

- 1) 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.
- 2) 다음과 같이 청구기각판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (3점)

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하시오. (4점)

이번 변리사시험에서 그나마 논란이 될 수 있는 문항이라고 생각됩니다. 설문(1)은, 확인대상발명의 특정과 확인의 이익에 대해 일반론으로 배점을 채우면 되겠습니다. 설문(2)는, 논란의 여지가 있는데, 사실관계상, 각하심결은 결과에 있어 정당하므로, 청구인용판결을 하는 것은 “불가능합니다.” 하지만, 청구인용판결과 청구기각판결의 경우 각각의 이유, 효과 및 문제점을 작성해야 하므로, 이 점을 문제점에서 작성하는 방향으로 푸는 것이 의도라고 생각됩니다. 설문(3)은 각하심결의 취소소송 심리범위를 묻는 문제입니다. 판례의 사실관계인 만큼, 이에 대해 작성하면 충분하겠습니다. 설문(4)는, 구체적 행위태양 제시의무를 주논점으로 하여, 기타 추정 규정 등을 부논점으로 작성할 수 있겠습니다.

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하시오. (5점)

- 1) 청구취지의 특정
- 2) 청구원인의 특정
- 3) 확인의 이익

I. 설문(1)

1. 확인대상발명(法140③)

권리범위확인심판청구 시, 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부해야 한다.

2. 청구취지의 특정(判例)

“확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.”

3. 청구원인의 특정(判例)

“확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.”

4. 확인의 이익

(1) 일반 判例

“확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실시발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없다.”(2011후2626)

(2) 동일성 판단 判例

“확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.”(2011후2626)

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장은 심리하지 않으면서, 독자적으로 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하시오. (8점)

1) 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점

1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

2) 다음과 같이 청구기각판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

II. 설문(2) - 1)

1. 판결의 이유

특허심판원은 확인대상발명의 특정 여부를 먼저 심리하고, 특정된 확인대상발명을 기준으로 확인의 이익을 판단해야 한다. 그러나, 확인대상발명의 특정 여부를 심리하지 아니하고 확인의 이익이 없다고 보아 각하한 원심결은 위법하다. 따라서, 심결은 취소되어야 한다.

(위 내용에는 논리적 오류가 있습니다. 확인대상발명이 불특정된 경우, 각하심결이 타당하므로 특허법원은 청구기각판결을 해야 하고, 청구인용판결할 수 없습니다. 위 내용은 가능한 청구인용을 하기위한 논리를 쥐어짜서 작성한 것입니다. 위 논리적 오류의 문제점은, 아래

3. 문제점에서 서술하고 있습니다.)

2. 효과

(1) 기속력

심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(法189③).

(2) 사안의 경우

청구인용판결을 하는 경우 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 기속력이 발생할 것이다(判例).

3. 문제점

(1) 소송비용 부담의 문제

1) 소송비용은 패소한 당사자가 부담하는 것이 원칙이다(민소법 제98조). 이는 행정소송법 제8조에 의해 심결취소소송에 준용된다.

2) 청구인용판결을 한 경우 소송비용은 피고가 부담해야 하는데, 이를 원고가 부담하도록 하였으므로, 청구인용판결에는 문제가 있다.

(2) 청구기각하지 않은 것의 문제

1) 확인대상발명의 특정 여부는 심판청구의 적법요건으로, 청구취지의 일부를 구성하고 직권조사사항이며 흠결 시 심결각하된다(法142).

2) 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않았다면, 확인대상발명은 청구취지로서 특정되지 않았다고 볼 수 있다.

3) 따라서, 확인대상발명이 특정되지 않았으므로, 심판청구는 부적법한데, 심판청구가 부적법하다고 각하심결한 원심결은 타당하다.

III. 설문(3) - 2)

1. 판결의 이유

- 1) 전술한 바와 같이 확인대상발명이 특정되지 않았으므로, 심판청구는 부적법한데, 심판청구가 부적법하다고 각하심결한 원심결은 타당하다.
- 2) 따라서 원심결은 결론에 있어서 타당하므로, 원고 청구를 기각하여야 한다.

2. 효과

- ① 청구기각판결을 한 경우 원심결인 각하심결이 확정된다.
- ② 다만, 각하심결의 확정이므로, 일사부재리의 효력이 발생하지 않을 것이다(法163).

3. 문제점

- 1) 법원이 원고의 청구를 기각하려면 원고가 주장하는 심결의 위법사유의 당부를 판단해야 하고, 그렇지 않은 경우 판단누락의 위법이 있게 된다(민사소송법451①(9)).
- 2) 특허법원은 확인대상발명의 C는 乙이 주장하는 C'과 사실적 관점에서 동일하다는 주장을 판단하지 않으면서, 甲의 청구를 기각하였으므로, 청구기각판결에는 판단누락의 문제가 있다.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (3점)

IV. 설문(3)

1. 제186조제6항 - 심결전치주의

2. 심결취소소송의 심리범위(判例)

“당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.”(2018후11360)

3. 사안의 해결

(1) 심리범위

심결취소소송의 소송물은 심결의 위법성 여부이므로 특허법원은 각하심결의 타당성을 다투는 범위 이내에서는 심결의 위법사유에 대해 제한 없이 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

(2) 본안심리 가부

특허법원의 심리범위는 각하심결의 위법성에 국한된다. 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우, 확인의 이익을 심리하여 확인의 이익이 인정된다면, 적법한 심판청구로서 각하심결이 부당하므로, 심결취소판결을 해야 하는 것이고, 본안 심리를 할 수는 없다.

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하시오. (4점)

V. 설문(4)

1. 구체적 행위태양 제시 의무(法126의2)

(1) 규정

(2) 사안의 경우

- ① 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명과 실시발명의 구성이 다르다는 주장만을 하고 있다.
- ② 따라서 甲은 해당 규정을 이용하여 乙이 구체적 행위태양을 제시하도록 할 수 있다.

2. 기타 규정

- ① 침해의 증명을 위해 자료제출명령(法132)을 이용할 수 있을 것이다.
- ② 손해배상청구소송인 경우, 손해배상청구권(法128) 및 과실의 추정(法130)을 활용할 수 있다.

[문제 - 3]

I. 특허권자인 甲의 특허발명(X)은 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’에 관한 것이고 乙의 비교대상발명(Y)은 ‘튜브형 화장품 용기의 노즐팁’에 관한 것이다.

II. 乙은 甲을 상대로 X는 기재불비사유가 있고 진보성이 부정되어 무효가 되어야 한다고 주장하며 무효심판청구를 제기하였다. 위 심판절차가 진행되던 중 甲은 X의 상세한 설명 부분을 정정하는 정정청구를 다음과 같이 하였다.

“X의 특허청구범위등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹 뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 정정청구는 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.”

III.

X 중 ‘하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가(印加, 전원을 공급·연결하는 일)하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁’은 Y의 ‘튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면을 구비하는 실리콘팁’에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 X의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, Y의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

X는 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것이다. Y에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다.

Y는 입술에 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, Y에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 Y의 기술적 과제에 반하는 것이거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다.

X는 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 Y로부터 예측하기 어렵다.

- (1) ‘특허무효심판절차’에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지 및 허용범위에 관하여 설명하시오. (9점)
- (2) 특허 오류 정정 범위에 포함되는 사항에 대해서 설명하시오. (5점)
- (3) 특허청구범위와 발명의 상세한 설명과의 관계를 설명하고 위의 II에 대해서 판단하시오. (8점)
- (4) 본 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법에 관하여 설명하고 위의 III에 대해서 판단하시오. (8점)

설문(1)은 단문 문제였으므로, 별다른 문제 없이 풀 수 있었을 것이라 생각합니다. 설문(2)는, 관련 판례(2014후2184)의 법리(분명하지 않은 기재의 명확화)를 작성하면 되는데, 이것만으로 배점을 채우기 어려우므로, 관련된 다른 일반론을 적어주면 되는 문항이었습니다. 설문(3)은 상기 판례의 법리를 통해 일반론을 작성하고, 사안포섭을 하면 되는 문제였습니다. 설문(4)는, 진보성 일반론을 작성하고, 주어진 사실관계에 “목차”를 적절히 붙여서, 진보성 인정으로 유도하면 되는 문제였습니다. 모두 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결을 그대로 가져온 문제로 파악됩니다.

(1) ‘특허무효심판절차’에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지 및 허용범위에 관하여 설명하시오. (9점)

I. 설문(1)

1. 특허정정을 할 수 있게 하는 취지

(1) 무효심판에서 특허의 정정의 의의

특허권자는 무효심판절차 내에서 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다.

(2) 취지

① “무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주”는 것이다(2014후2184).

② 즉, 특허무효심판에서 심판청구인의 무효사유 주장에 대응하여 특허권자에게 방어적 기회를 줌으로써 형평성을 도모하기 위함이다.

2. 허용범위

(1) 정정의 종류(法136①③)

명세서·도면의 범위에서 청구범위를 감축하거나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 할 수 있으며, 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위에서 잘못 기재된 사항을 정정할 수 있다.

(2) 정정의 제한 - 실질적 확장변경의 금지(法136④)

명세서·도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(배점상 판례 기재 가능).

(3) 정정의 제한 - 독립특허요건의 만족(法136⑤)

① 청구범위 감축·잘못 기재된 사항의 정정의 경우 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

② 다만, 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우(法133의2⑥)에는 출원 시 특허받을 수 있을 것이라는 요건을 판단하지 아니한다. 중복심리를 막기 위함이다.

(2) 특허 오류 정정 범위에 포함되는 사항에 대해서 설명하시오. (5점)

II. 설문(2)

1. 특허 오류 정정(法136①(3))

2. 오류 정정의 의미 判例

“청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다.”

3. 오류 정정의 범위

분명하지 않은 기재의 명확화(法136①(3))는, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(배점상 기재한 것으로, 다른 기재로 배점을 채웠다면, 생략할 수 있음).

(3) 특허청구범위와 발명의 상세한 설명과의 관계를 설명하고 위의 II에 대해서 판단하시오. (8점)

III. 설문(3)

1. 청구범위와 발명의 설명과의 관계

(1) 각각의 기능

- 1) 청구범위는, 권리범위를 특정하고 이를 공시하기 위한 수단이다.
- 2) 발명의 설명은, 발명을 상세하게 설명하여, 공중에게 발명을 공개하기 위한 수단이다.

(2) 청구범위에 기재되지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함된 경우 判例(2014후2184)

“청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정하는 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로,

특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.”

2. 사안의 경우 - II에 대한 판단

- ① X의 특허청구범위에는, 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있다. ② 또한, 발명의 설명에는, 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹 뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다.
- ③ 다만, 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항(고밀도 플라스틱, 복합물 등)이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다. ④ 따라서, 위의 II의 경우, “분명하지 않은 기재의 명확화”에 해당하지 않으므로, 정정은 인정될 수 없다.

(4) 본 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법에 관하여 설명하고 위의 III에 대해서 판단하시오. (8점)

IV. 설문(4)

1. 진보성 판단 법리(法29②)

통상의 기술자에게 용이한 발명은 특허될 수 없다. 진보성은 선행발명과 출원발명의 차이점을 특정하고 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 구성의 곤란성·목적의 특이성·효과의 현저성을 기준으로 판단한다.

2. 사후적 고찰의 금지(2010후2537)

(1) 진보성의 판단 법리 判例

“발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다. 그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(줄이거나 생략 가능).

(2) 사후적 고찰의 금지 判例

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.”

3. 사안의 해결 - 위의 III에 대한 판단

(1) 재질에 관한 차이점

① X 중 열저장 팁은 Y의 실리콘팁에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. ② 그러나, X의 열 저장 팁과 Y의 실리콘팁은 재질에서 차이가 있다.

(2) 기술적 과제 및 해결수단에 관한 차이점

① X는 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것인데, Y에는 그러한 기술적 과제 및 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다. ② Y에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 Y의 기술적 과제에 반하는 것이거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다.

(3) 효과의 예측가능성

① X는 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, ② 이러한 효과는 Y로부터 예측하기 어렵다.

(4) 소결

① 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 Y로부터 X의 열 저장 팁을 쉽게 도출할 수 없다. ② 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 X의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

[문제 - 4]

甲은 乙을 상대로 ‘롤방충망의 록킹구조’에 관하여 다음 표와 같은 내용으로 소극적권리범위확인 심판을 청구하였다.

	확인대상발명	특허발명	공지기술
공통점	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	
세부작동 및 구조 (구성요소 2)	버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지(hinge, 경첩)축을 중심으로 ‘회전’가능하게 장착	슬라이더가 지지부재의 이동공에 슬라이딩 가능하게 장착되어 전후방향으로 이동	
명세서		- 종래의 권취(捲取, 실, 코일 따위를 두루마리 형태로 등글게 말거나 감는 일)식 방충망은 슬라이더의 양측을 고정부가 지지하고 있기 때문에 장시간 사용 시 방충망을 잡아당기는 권취 수단의 힘에 의해 슬라이더의 중심부가 상방향으로 휘어지게 변형되어 걸림돌기가 걸림턱에 잘 결합되지 않게 되는 문제점이 있다. -슬라이더가 슬라이딩되는 슬라이딩 방향, 즉 상하 방향에 대한 수직방향인 전후 방향으로 이동하여 후방향으로 절곡된 걸림부와 결합되어 방충망을 고정시킬 수 있게 됨으로써 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분	

		리시킬 수 있다. -가이드 돌기가 형성된 슬라이더와 이를 둘러싸고 있는 가이드홈, 스프링 등의 작동방식 등을 구체적으로 기재하고 있다.	
개시사항			-손잡이를 하강시키면 고정구의 고정축이 고정프레임이 형성된 걸림턱에 걸리면서 잠금되고, 고정구를 당기면 그 잠금을 해제하는 회전당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망 -‘록(lock) 바하우징 내부에서 축을 중심으로 움직이며 판스프링으로 탄성적으로 지지되는 록 바가 결합되고, 록 바에 형성된 록 리브(lock rib)가 가이드 프레임의 양측에 설치된 걸림턱에 걸리면서 잠금되며, 사용자가 푸쉬 버튼을 눌러 잠금을 해제하는’회전누름식 방충망
과제해결원리	버튼부재의 힌지(hinge, 경첩)축을 이용한 회전누름식 잠금장치	슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망 잠금장치를 구현	

- (1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준에 대하여 설명하시오. (9점)
- (2) 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법에 관하여 설명하시오. (8점)
- (3) 위의 사안에 대하여 판단하시오. (3점)

문제-3까지 이미 많은 시간이 소요되었을 것이기에, 문제-4를 보고 많은 분들께서 당황하셨을 것이라고 판단됩니다. 다만, 문제-4는 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결을 그대로 가져온 문제입니다. 해당 판결은 정정심결 전원합의체 판결(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후 2522 전원합의체 판결)의 관련 권리범위 확인심판 사건이었습니다. 설문(1)은 침해 판단 일반론을 기재하면 되고, 설문(2)는 과제해결원리 동일성 단문을 작성하면 되는 문제였습니다. 설문(3)은, 단순히 사실관계에 있는 내용들을 그대로 베끼면서 과제해결원리가 다르다는 결론을 내면 되는 문제였습니다.

(1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준에 대하여 설명하시오. (9점)

I. 설문(1)

1. 특허발명의 권리범위

청구범위에는 보호받으려는 사항을 적어야 하므로(法42⑥) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의해 정하여진다(法97). 구성요소완비 원칙에 의하되 균등론이 인정된다(判例).

2. 보호범위 속부 여부의 판단

(1) 문언침해 判例(2010다79839)

“특허발명의 보호범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품에 그대로 포함되어 있어야 한다.”

(2) 균등침해 법리

1) 취지(判例)

“출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.”

2) 요건

침해품에 청구범위 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, ① 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, ② 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 변경하는 것이 통상의 기술자에게 용이하다면, ④ 자유실시기술이라는 사정또는 ⑤ 의식적 제외된 사정이 없는 한 청구범위 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 판례가 인정하는 법리이다.

3) 입증책임

① 과제 해결원리 동일성 ② 변경 가능성 및 ③ 변경 자명성 요건은 적극적 요건으로 특허권자가, ④ 자유실시기술 및 ⑤ 의식적 제외된 사정은 소극적 요건으로 실시자가 입증책임을 진다.

(2) 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법에 관하여 설명하시오. (8점)

II. 설문(2)

1. 과제 해결원리의 고려 취지(2017후424)

“특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.”

2. 과제 해결원리의 동일성 판단

(1) 종래 判例

“확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다.”(2007후3806)

(2) 최근 判例(2012후1132)

“청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”

(3) 검토

최근 판례는 발명전체설의 입장을 취한 것으로 파악되며, ‘기술사상의 핵심’이라는 다소 추상적인 표현의 사용을 토대로 과제 해결원리를 넓게 해석할 여지를 주었다는 의의가 있다.

3. 공지기술 참작의 법리

(1) 참작의 취지

“전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.”(2017후424)

(2) 판단의 법리

“선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

다만, 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체해서는 안 된다.”

(3) 위의 사안에 대하여 판단하시오. (3점)

III. 설문(3)

1. 구성요소의 대비

- ① 확인대상발명에는, 특허발명의 구성요소 1, 3 및 4와 동일한 구성요소가 포함되어 있다.
- ② 다만, 특허발명의 구성요소 2는 슬라이더가 지지부재의 이동공에 슬라이딩 가능하게 장착되어 전후방향으로 이동하는 데 반해, 확인대상 발명의 대응 구성요소는 버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지축을 중심으로 ‘회전’ 가능하게 장착되어, 양 구성요소는 그 세부 작동 및 구조에서 차이가 있다.

2. 발명의 설명과 공지기술의 참작

- ① 특허발명의 발명의 설명에는, 종래기술의 문제점을 지적하면서, 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분리시킬 수 있다는 내용이 기재되어 있다.
- ② 공지기술에는, 회전당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망과, 사용자가 푸쉬 버튼을 눌러 잠금을 해제하는 회전누름식 방충망이 개시되어 있다.

3. 과제해결원리의 동일성 판단

특허발명의 과제해결원리는 슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망 잠금장치를 구현하는 것인데 반해, 확인대상발명의 과제해결원리는 버튼부재의 힌지축을 이용한 회전 누름식 잠금장치에 관한 것이다. 따라서, 확인대상발명은 특허발명과 같은 과제해결원리를 채택하지 않고 있다.

(추가적으로, 공지기술에 이미 회전 방식의 방충망이 기재되어 있으므로, 특허발명의 과제해결원리를 회전 가능하게 장착되는 방식까지 포함하도록 상위개념화(넓게 파악)할 수 없고(과제해결원리를 좁게 해석해야 하고), 따라서 과제해결원리가 상이하다고 기재할 수 있음)

4. 결론

확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.